

1517457-05.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517457-05.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517457-05.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2209909/2019 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista, 6835/2019 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAN MARQUES DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo 1781/19

VISTOS.

JONATAN MARQUES DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, porque consta que no dia 19 de julho de 2019, por volta de 13:30 horas, à Rua João Carlos Amat, 5, Itaim Paulista, nas proximidades de estabelecimento de ensino, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, cerca de 33g de cocaína em forma de crack e 51.3g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Defesa preliminar a fls. 120.

A denúncia foi recebida a fls. 122.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de olheiro, afastamento das agravantes, pena mínima, com regime mais brando, substituição e recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, as negativas do acusado e os argumentos da combativa defesa não arredaram os fortes indícios e provas diretas que derivaram contra o réu, em especial, pelos laudos periciais, testemunhas inquiridas e declaração do próprio acusado, que nada de exculpatório trouxe aos autos.

A materialidade do crime veio bem estampada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23, dando conta dos 16 invólucros de maconha, das 92 unidades de crack, localizados em poder do réu.

Em complementação, o exame químico toxicológico de fls. 97, atestou que as substâncias localizadas em poder do acusado eram positivas para tetrahydrocannabinol e cocaína.

Na fase inquisitiva o réu alegou que atuava como olheiro, ou seja, só protegia o serviço, e se estava sozinho naquele momento, foi porque o vendedor havia saído para comer e ficou no lugar dele para ajudar, fls. 07.

Em seu interrogatório judicial, o acusado relatou que eu estava no tráfico, mas somente como olheiro, na campana. Campana não pega na bolsa, então eu não servi ninguém. A pessoa que estava servindo foi comigo foi também levado para delegacia, mas foi solto e eu acabei sendo preso. Não conhecia os policiais. Nunca fui preso antes. Tenho 20 anos de idade.

Por um lado o réu confessa que estava realmente no local dos fatos, porém agia como olheiro. Esta é também a tese defensiva, no sentido de que a conduta dele há que ser desclassificada para aquela prevista no artigo 37 da Lei de Drogas.

No entanto, as provas dos autos, como adiante se verá, não fornecem guarida a tese defensiva. Os policiais civis foram firmes em dizer que na ocasião, o réu efetivamente vendia drogas a terceiros, de sorte que sua conduta se amoldou perfeitamente ao tipo legal descrito na denúncia.

Não há porque se acreditar que os policiais resolvessem, do nada, dispensar o verdadeiro traficante, mantendo o réu como autor do delito em questão, no afã único de acusa-lo falsamente. Ainda mais quando as partes são desconhecidas como no presente caso, e não há um indicio sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória teria sido produzida com a finalidade de prejudicar o acusado.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, as circunstâncias dos autos, tais como, a grande quantidade do tipo de droga encontrada, a forma como estavam acondicionadas, em papetes distintos, prontos para a venda individual, somado ao local em que o réu foi abordado, a fala firme dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância. E assim é porque os policiais civis responsáveis pela prisão do acusado, Fernando dos Santos Guberev e Francisco Egidio Ferreira de Andrade, ouvidos nos autos, relataram de forma firme e segura, em uma só voz que recebemos uma denúncia que no local, que é bem conhecido ponto de venda de drogas, tanto que já fizemos mais de dez prisões no mesmo local. Lá chegando, fizemos breve campana, e vimos o réu, através de binóculo, em conduta de venda de entorpecentes. Duas pessoas se aproximaram dele, ele foi até o local onde estavam as drogas escondidas e depois voltar. Quando estacionamos a viatura, vimos uma segunda compra. Como o réu estava sentado, ele não viu a gente chegar. Ele foi abordado e confessou que estava a serviço do tráfico, mas somente como olheiro. Fomos ao local onde ele escondia as drogas, tinha uma pedra em cima das drogas, bem perto dele. Reconhecemos o réu e não o conhecíamos anteriormente. O esconderijo das drogas nós vimos ele indo até o local. Não encontramos dinheiro, porque geralmente as drogas e o dinheiro não ficam juntos. No local só estava o réu. Confirmaram que nas proximidades do local em que o réu estava havia uma escola, eles atuavam no muro da escola. Reconheceram o acusado e não o conheciam anteriormente.

Os policiais narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde uma denúncia anônima de tráfico no local, a conduta suspeita do réu pegando algo e entregando a terceiros por duas vezes, o encontro da droga na arquibancada próxima a uma unidade escolar, sua confissão informal ao declarar que atuava como olheiro, até final prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Com efeito, há muito tempo já se encontra superada a sustentação de ser insuficiente a prova policial.

Neste sentido: "Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Tóxico. Depoimento prestado por policial. Prova firme e coerente. Apreensão em fiscalização de Trânsito e de rotina. Circunstância que justifica o não arrolamento de testemunha alheia ao quadro policial. Recurso não provido". (Apelação criminal. 126.697-3, rel. Des. Álvaro Cury. RJTJESP n. 138/451).

Em que pesem os argumentos do nobre Defensor Público alegando em síntese que o réu é olheiro e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário. Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder do réu, a forma como estavam embaladas, de forma individualizada, prontas para venda, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

No mais, nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia ou mesmo possibilitar a desclassificação para uso próprio. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição ou desclassificação pretendida pela defesa. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Apenas um reparo merece a peça acusatória e tal se dá com relação à agravante prevista no artigo 40 da Lei 11.343/06.

E isso porque além de se tratar de período de férias escolares não se encontra nos autos qualquer descrição sobre a referida Instituição, de sorte que com relação à agravante as provas são frágeis e não suficientes para sua comprovação.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é primário, menor de 21 anos de idade, pelo que, fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, a despeito da discordância apresentada pela ilustre representante do Ministério Público, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem quaisquer antecedentes, é jovem e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a capacidade lesiva de uma das drogas em questão, tratando-se de maconha, reduzo a pena base em 1/3, perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa. O valor do dia multa será o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar JONATAN MARQUES DE JESUS, como incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, sem qualquer mácula em sua vida, foi solto no curso do processo, compareceu a todos os atos para os quais foi chamado.

Além disso comprovou que encontra-se trabalhando, sendo que fazê-la retornar aos sistemas carcerários revela medida excessivamente drástica como forma de repressão e retribuição.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço.

Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram. No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA